RECURSO ESPECIAL Nº 2229184 - SP(2025/0317268-6)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO EM PATAMAR MENOR.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 1523777-37.2020.8.26.0228, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 385/386):

> DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Bruno De Oliveira Santos contra sentença que o condenou por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 29, caput, e art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Condenação às penas de 6 anos de reclusão e multa de 600 dias-multa, devido a fatos ocorridos em 11 de novembro de 2020. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se há insuficiência de provas para absolvição; (ii) se é cabível a desclassificação para uso pessoal; (iii) se deve ser afastada a agravante pela calamidade pública; (iv) se deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. A condenação por tráfico de drogas foi mantida, pois as provas colhidas legitimam a responsabilidade criminal do apelante, afastando a insuficiência de provas. 4. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada, pois a condição de usuário não afasta a de traficante, conforme jurisprudência dominante. 5. A agravante pela calamidade pública foi afastada, pois não há nexo de causalidade entre a pandemia e a prática do crime. 6. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 foi aplicada, reduzindo a pena em 1/2, devido à ausência de provas de dedicação a atividades ilícitas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Pena readequada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito.

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7

Nas razões, a parte recorrente aponta a violação do art. 28, *caput* e § 2º, da Lei n. 11.343/2006. Sustenta que não há elementos concretos demonstrando a traficância, ao contrário, indicam a posse de entorpecente para uso próprio, notadamente considerando a pequena quantidade.

Argumenta que o acondicionamento em porções não afasta o uso, pois usuários também adquirem drogas fracionadas e não houve abordagem de suposto comprador.

Subsidiariamente, indica ofensa ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que a quantidade de drogas não justifica a modulação da minorante, devendo ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

Ao final, requer provimento para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela ampliação da minorante do tráfico.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 428/433), o recurso foi admitido na origem (fls. 434/435).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso especial (fls. 444/455).

É o relatório.

VOTO

O recurso merece parcial acolhimento.

Quanto à desclassificação para conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 389/392 – grifo nosso):

> [...] Em juízo e, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa e, ao final, o apelante foi interrogado.
>
> **O policial civil Lineker Cesar Matowiski relatou que, na data dos fatos, estava em diligência pela região da Delegacia, um local já conhecido pelo tráfico de drogas. Ali, pararam e observaram por alguns minutos, quando viram um indivíduo sem camisa, com tatuagem, que recebia algo de pessoas. Esse rapaz ia até onde estava o apelante, pegava algo e entregava para as outras pessoas. Decidiram pela abordagem, momento em que o outro indivíduo correu, enquanto o apelante permaneceu no local. Informalmente, o apelante alegou que era usuário. A droga foi encontrada muito próxima a ele, no chão, dentro de um buraco. O apelante também deu outras versões no trajeto até a Delegacia, chegando a dizer que estaria ali para comprar pinga, mas não havia dinheiro com ele.**

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7

O policial civil Phylipe Marion Mafra narrou que estavam de campana no local e visualizaram que um rapaz com tatuagem e o apelante ficavam cada um de um lado da calçada. Pessoas chegavam e entregavam algo ao rapaz tatuado, que então ia até ao apelante, pegava algo e entregava à pessoa. Em uma dessas dinâmicas, chegou a ver o apelante pegando algo e entregando ao rapaz com tatuagem, que repassou a uma terceira pessoa. Realizada a abordagem, conseguiram deter somente o apelante, e próximo a ele, debaixo de uma pedra, encontraram as drogas. O apelante alegou informalmente que morava pelo local, que estaria ali bebendo, e depois disse que estaria trabalhando. O policial não conhecia o réu até então, mas depois dos fatos continuou avistando-o no mesmo local descrito na denúncia.

A testemunha arrolada pela defesa declarou que conhece o apelante em razão de ter um bar e ele ser seu cliente. Seu bar fica na Rua Valorbe, n º 456, próximo de onde o apelante foi detido. Contou que presenciou a prisão. Estava na calçada e viu que o apelante tinha ido ao local para comprar droga, pois ele é usuário, mas o traficante correu e o apelante acabou sendo detido pelos policiais. Explicou que o apelante havia lhe dito que iria comprar droga naquele momento. Estava também com outro rapaz, presenciou os fatos, mas que se encontra acamado e não pode ser testemunha. Disse que conhece também a pessoa que vendia as drogas, que se encontra presa.

Por fim, o apelante foi interrogado, negou a traficância. Disse que foi ao local para comprar cocaína, pois é usuário, próximo do bar da testemunha Durval, mas acabou sendo abordado pelos policiais, no local onde ficava o traficante. Usava entre quatro e cinco porções de cocaína por dia, pagando cinco reais por unidade. Trabalha como servente de pedreiro e ganha entre cem e cento e vinte reais por dia. Acrescentou que mora com irmã e tem três filhos, os quais também ajuda a sustentar.

Esta é a prova oral produzida.

A defesa pretende a absolvição, sustentando que as provas produzidas se limitam aos depoimentos dos policiais civis, os quais não seriam terceiros desinteressados e, portanto, não seriam neutros nas narrativas.

Apesar das argumentações da defesa, ela não apresentou quaisquer elementos que lançassem dúvidas acerca da lisura dos depoimentos dos agentes públicos, limitando-se a contextos argumentativos.

[...]

Por sua vez a negativa do apelante não convence e, além disso, destoam das demais provas produzidas nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes, harmônicos e uníssonos dos agentes policiais que atuaram na operação policial. Assim, para além das combatíveis teses defensivas, fato é que pelas circunstâncias acima expostas, diante da operação realizada pelos policiais civis que levou à prisão em flagrante do apelante em posse das drogas apreendidas, não resta dúvida da prática de tráfico de drogas.

Assim, a responsabilidade penal pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n º 11.343/2006 imputada ao apelante na r. sentença é incensurável, não havendo que se falar em ausência de provas para sustentar a condenação nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, impossível o acolhimento da tese defensiva quando a condição de usuário art. 28, caput da Lei n.º 11.343/2006, até porque, a condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante.

De mais a simples condição eventual de usuário não afasta o apelante do tráfico. Aliás, é muito comum que o traficante também seja usuário ou que o consumidor de drogas pratique o tráfico para sustentar o vício dele.

Assim, inviável o acolhimento da tese da desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo próprio.

[...]

Como se observa, a Corte de origem concluiu pela manutenção da condenação do recorrente, por tráfico de drogas, baseando-se na dinâmica dos fatos e nas provas colhidas na instrução processual, notadamente, o contexto da prisão em flagrante, que foi antecedida pela verificação, por policiais em campana, da entrega de

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7

algo pelo recorrente para terceiro e deste para outras pessoas, posteriormente identificado como 12 invólucros plásticos de cocaína.

Diante desse contexto fático-probatório, para se concluir de modo diverso e desclassificar a conduta para porte de drogas para uso pessoal, seria necessário o revolvimento dos referidos elementos, providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.026.533/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 24/6/2022; e AgRg no AREsp n. 2.092.396/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/6/2022.

No tocante à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a Corte *a quo* assim se manifestou (fls. 396/967 – grifo nosso):

> [...] Na terceira fase, não foram aplicadas as causas de diminuição de pena previstas no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a MM. Juíza a quo entendeu que as provas produzidas indicam que o apelante se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida.
>
> **Com a devida vênia, não há nos autos elementos seguros que indiquem de forma efetiva que o apelante se dedica a atividades ilícitas ou que integre organização criminosa. A prova oral não demonstrou com segurança que o apelante faz da traficância seu meio de vida. Inclusive, mesmo indicado pela testemunha que ele ainda frequenta o local, não há informação nos autos que leve a crer em seu envolvimento contínuo com o tráfico de drogas ou que o ligue à traficância local. Assim, é de rigor a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, presentes, no caso, todos os requisitos legais.**
>
> **Em consequência, reconheço a causa de diminuição da pena na terceira fase do cálculo, e reduzo as penas em 1/2, pela causa de diminuição do art. 33, § 4º, do mesmo diploma. Redução mediana, pela quantidade de droga apreendida.**
>
> [...]

Sobre o tema, esclareço que o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do *quantum* de redução da pena, mas apenas os requisitos para a incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.

Na hipótese, o Tribunal de origem aplicou o redutor em 1/2, considerando a quantidade das drogas apreendidas (**6,9 g de cocaína** – fl. 388).

Ainda que seja possível a modulação da minorante com base na quantidade e natureza das drogas, esta Corte Superior tem rechaçado tal fundamento quando se trata de pequena quantidade, como no caso.

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7

Desse modo, é de rigor a reforma do julgado para a aplicação da minorante em seu patamar máximo.

Nessa linha:

> PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO EM MENOR PATAMAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS SOBRE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> 1. O tráfico privilegiado admite a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, quando presentes os requisitos legais e ausentes circunstâncias que desabonem a conduta do agente.
>
> **2. Embora a quantidade de droga apreendida não seja inexpressiva, também não se mostra relevante a ponto de justificar, por si só, a modulação da fração de redução em patamar inferior ao máximo previsto em lei.**
>
> 3. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, c, e 44 do Código Penal.
>
> 4. Agravo regimental improvido.
>
> (AgRg no HC n. 989.289/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 26/6/2025 - grifo nosso).

> PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
>
> **1. Cuidando-se de réu primário, sem antecedentes, com quem foi apreendida ínfima quantidade de droga - 1 porção de maconha, pesando 1,24 g, e 15 porções de crack, pesando 3,79g -, tem-se que a eventual utilização da sua casa como ponto de tráfico não tem o condão de, por si só, revelar sua dedicação a atividade criminosa, em especial pela "pequena nocividade na conduta". (AgRg no HC n. 870.096/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)**
>
> **- Dessa forma, observa-se que o contexto dos autos não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo a fração de diminuição incidir em seu máximo, haja vista a ausência de fundamentos concretos que recomendem fração mais gravosa. Incide, assim, a causa de diminuição da pena na fração de 2/3, resultando uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto. No mais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.**
>
> 2. Agravo regimental provido para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício, reconhecendo o tráfico privilegiado.
>
> (AgRg no HC n. 983.138/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 21/8/2025 - grifo nosso).

Por conseguinte, considerando os demais termos da dosimetria aplicada na instância de origem, fixo a pena do recorrente em **1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa**.

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7

Ante o exposto, **conheço parcialmente** do recurso especial e, nessa extensão, **dou**-lhe **provimento** para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 2/3, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Documento eletrônico VDA56076583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/06/2026 às 00:59:04 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 23/04/2026 08:06:14
Código de Controle do Documento: 96a2a985-9fb5-4b6b-b975-e470694852e7